

1501492-67.2021.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Flavia de Cassia Gonzales de Oliveira

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/02/2022

... condição de dependente químico não elide a prática do delito de tráfico de drogas." (TJAC - Processo: EI 10414920108010001 AC 0001041-49.2010.8.01.0001 -

Relator(a): Pedro Ranzi - Julgamento: 27/04/2011 - Órgão Julgador: Tribunal Pleno - Publicação: 30/04/2011).

"APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVA. SUFICIÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

2ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Sala 05/07, Alemães - CEP 13417-100, Fone: (19)3433-4177, Piracicaba-SP - E-mail: piracicaba2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1501492-67.2021.8.26.0599

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2264061/2021 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 20512083 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO,

2666/21/922 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 2264061 - 04º D.P. PIRACICABA,

2666/21/922 - 04º D.P. PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOAO VITOR SANTOS DE OLIVEIRA e outro

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

*

Réu Preso

Tramitação prioritária

Aos 01 dias do mês de fevereiro de 2022, à hora designada, por meio da Ferramenta Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG 284/2020, apresentaram-se a Exma. Sra. Dra. FLAVIA DE CASSIA GONZALES DE OLIVEIRA, MMª Juíza de Direito, o representante do Ministério Público, Dr. Denis Peixoto Parron e o(a) Dr. Ricardo Teles de Souza (def.João Victor) e dr. Jose Carlos Santão (Def.Jean), as testemunhas arroladas em comum pelas partes Anderson Cleiton Floriano e Robison Alas Gonçalves, e as testemunhas arroladas pela defesa do réu Jean: Marlene da Costa Pereira.

Ausente a testemunha arrolada pela defesa do réu Jean: Elenita de Jesus Souza, a qual foi devidamente intimada, mas não compareceu virtual e nem presencialmente. Fica consignado que foi assegurado o direito de entrevista do(a)(s) acusado(a)(s)

com seu(sua)(s) defensor(a)(es), em reunião virtual apartada, no estrito cumprimento do artigo 185, § 5º, do C.P.P., tendo a MM Juíza feito ao(a)(s) acusado(a)(s) a observação determinada no artigo 186 do Código de Processo Penal. INICIADOS OS TRABALHOS, com a concordância das partes, pela MM. Juíza foi(ram) colhido(s) o(s) depoimento(s) da(s) testemunha(s) comuns (Anderson e Robison), da defesa (Marlene) pelo sistema virtual e, em seguida, interrogado(a)(s) o(a)(s) réu(ré)(s) (João Victor e Jean).

Pelo defensor do corréu Jean foi dito que desiste da oitiva da testemunha Elenita de Jesus Souza.

Em seguida, pela MM Juíza foi deliberado:

Homologo a desistência da Defesa do réu Jean, em relação à testemunha Elenita de Jesus Souza.

“Não havendo mais provas a serem produzidas, encerro a instrução, determinando às partes que passem aos debates orais:

Dada a palavra ao(à) ilustre representante do Ministério Público, manifestou-se sua Excelência nos seguintes termos:

“MM.Juíza, JOÃO VITOR SANTOS DE OLIVEIRA e JEAN SEBASTIÃO RIBEIRO BARBOSA estão sendo processados como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, c.c. o artigo 29 do CP.

DOS FATOS, COM INDICAÇÃO DAS PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 27 de setembro de 2021, por volta de 13h00min, na Rua das Oliveiras, Bairro Mário Dedini, nesta cidade e Comarca de Piracicaba/SP, JOÃO VITOR SANTOS DE OLIVEIRA, qualificado e indiciado às fls. 06/07 e 33/35, e JEAN SEBASTIÃO RIBEIRO BARBOSA, qualificado e indiciado às fls. 10/11 e 37/38, atuando em conluio e com unidade de desígnios delituosos, traziam consigo e transportavam, para entregar ou fornecer ao consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, 31 (trinta e um) invólucros plásticos contendo Cannabis Sativa L, “maconha”, com peso líquido de 33,3g (trinta e três gramas e três decigramas), e 28 (vinte e oito) invólucros em plástico e papel alumínio contendo cocaína, com peso líquido de 6,5g (seis gramas e cinco decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, JOÃO e JEAN -que desde a adolescência se dedicam ao tráfico de drogas- se ajustaram para a prática de tráfico de drogas utilizando-se da motocicleta Honda CG/Titan, ESD-8939, Sumaré/SP. Ocorre que, quando transportavam entorpecentes, foram interpelados por policiais militares que suspeitaram do comportamento do condutor - a motocicleta estava sem emplacamento, em alta velocidade e realizando manobras perigosas. Não obedecendo os sinais de parada, JEAN, trazendo JOÃO como passageiro, iniciou fuga pelas ruas da cidade.

A abordagem policial somente foi possível após os denunciados sofrerem queda da moto no bairro Bosque dos Lenheiros. Em busca pessoal, com JOÃO foram encontradas as drogas acima descritas e R\$5,00 (cinco reais) em espécie (fls. 24/27); com JEAN - que ainda seguiu em fuga e foi abordado adiante - nada de ilícito foi encontrado. Informalmente, os denunciados confirmaram a aquisição da droga no bairro Santa Teresinha para venda no Bosque dos Lenheiros (fls. 04/07).

Na delegacia, porém, ambos negaram relação com a droga apreendida (fls. 08/11). O exame pericial constatou a presença de tetrahydrocannabinol e cocaína nas substâncias apreendidas (auto fls. 19/20 e laudo fls. 29/31).

As circunstâncias da prisão, notadamente a condição pessoal dos denunciados - cumprimento recente de medidas socioeducativas pela prática de atos infracionais análogos ao tráfico de drogas -, a fuga dos policiais bem como a apreensão de considerável quantidade de cocaína e maconha -incompatíveis com a alegação de mero uso pessoal -, tornam certo que os denunciados, conluídos, transportavam e traziam consigo os entorpecentes com a finalidade de comércio ilícito.

DA PROVA NA FASE JUDICIAL

Anderson Cleiton Floriano - Policial Militar - narrou que estava em patrulhamento e viu uma motocicleta com duas pessoas. O condutor fez manobra de levantar uma das rodas. Iniciou acompanhamento que se prosseguiu por vários bairros, sendo que o condutor da motocicleta desobedecia as ordens de parada. Quando ele acessou uma trilha na área verde do bairro Gilda, o condutor perdeu o controle da motocicleta e

o garupa caiu no solo. Este foi abordado e o condutor continuou em fuga. Manteve a perseguição e com apoio de outras viaturas, deteve-o. O condutor da motocicleta foi identificado como JEAN. O garupa, como JOÃO VITOR. Com este, localizaram uma pochete com porções de maconha e cocaína e dinheiro, R\$5,00. Os dois confirmaram que tinham pegado as drogas no Santa Terezinha e iriam comercializar no bosque dos Lenheiros. O condutor fugiu com a motocicleta desrespeitando várias leis de trânsito, em velocidade incompatível, bem acima do permitido nas vias públicas. No mesmo sentido, o PM Robison Alas Gonçalves.

Os réus negaram os fatos.

Da caracterização do crime de tráfico de drogas:

As palavras dos agentes policiais merecem credibilidade e possuem força probatória suficiente para a prolação da sentença condenatória, mormente porque não conheciam o réu e não tinham motivo algum para incriminá-lo gratuitamente (Apelação Criminal nº 990.08.153847-4, 8ª Câmara Criminal, rel. Des. André de Oliveira, julgada em 13/03/2009).

As provas angariadas não deixaram dúvidas acerca da configuração do tráfico de drogas.

Com relação ao argumento do réu de que não chegou a nada comercializar, nem se alegue que tal seria necessário, pois não é necessária a prática de ato de comércio, ainda mais quando não há dúvida de que o entorpecente seria destinado à venda. No ponto: "A prova mostra, ainda, que a droga era destinada ao comércio, mormente pela expressiva quantidade, pela forma de acondicionamento e pela postura do acusado, que inclusive admitiu o comércio espúrio. De mais a mais, nunca é demais lembrar que é desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente traga consigo ou guarde a droga para essa destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige qualquer resultado.

Dentro dessas premissas, não se tem dúvida de que o entorpecente apreendido seria destinado à venda, de sorte que o delito está bem caracterizado. A condenação do recorrente pelo tráfico, portanto, foi bem decretada." TJ/SP, 0005411-25.2010.8.26.0050 Apelação, Relator(a): Pinheiro Franco, Comarca: São Paulo, Órgão julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 10/11/2011, Data de registro: 11/11/2011).

Saliento que o fato de se declarar usuário de drogas, não afasta a possibilidade de que o mesmo exerça a traficância ilícita de entorpecentes, até porque muitos dependentes de tóxicos utilizam desse expediente para financiar o próprio vício. Nesse sentido: "A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente preponderando a última, de maior gravidade" (TJSP - HC 42.229- 3 - Rel. Onei Raphael - RJTJSP 10/498).

E não há se falar em absolvição fundada em suposta dificuldade financeira, uma vez que esta situação não caracteriza estado de necessidade, nem se amolda a qualquer excludente de culpabilidade. Além disso, não poderia o agente criminoso valer-se de meio ilícito para obter seu sustento. "Crime de tráfico - Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade do delito - Transporte interestadual - Confissão da ré que se ajusta a esse quadro - Estado de necessidade afastado - Justificativa de dificuldades financeiras que não afasta a punibilidade - Pena base fixada no mínimo legal previsto, compensada a causa de aumento com a causa de redução por frações iguais - Pena adequada - Recurso não provido." (Apelação 990080746367, 16ª Câmara de Direito Criminal TJ/SP, relator Newton Neves, julgado em 23.03.10).

Da pena:

Folha de antecedentes e certidões já providenciadas (fls. 48/58): JOAO VITOR SANTOS DE OLIVEIRA e JEAN SEBASTIÃO RIBEIRO BARBOSA são primários e menores de 21 anos - inobstante, ostentam anotações recentes na Vara da Infância e Juventude, inclusive cumprimento de medidas socioeducativas, pela prática de atos infracionais análogos ao tráfico de drogas (fls. 50 e 56/57).

Pena no mínimo legal.

Não é possível a diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

O réu ostenta envolvimento pela prática de ato infracional grave e trazia consigo e

tinha sob sua guarda grande quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes. Então, cuida-se de traficante de certa envergadura, longe da figura do pequeno traficante que a lei penal procura beneficiar.

As circunstâncias especiais do fato, a quantidade, a natureza e a diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas, mais nocivas à saúde e com maior potencial de levar o usuário à dependência devem ser levadas em consideração na dosimetria da pena, servindo-se para afastar o benefício legal acima mencionado. (RT 775/559). E mais, cabe destacar que o disposto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas instituiu o denominado tráfico privilegiado a prestigiar o princípio da individualização da pena, tendo por objetivo diferenciar as penas impostas ao traficante eventual e àquele que habitualmente se dedica à atividade criminosas.

E nessa seara, após longa discussão doutrinária e jurisprudencial, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus nº 118.533/MS, reconheceu que a figura do “tráfico privilegiado de drogas”, contida no § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, não ostenta natureza hedionda, sendo, posteriormente, acompanhado pelo E. Superior Tribunal de Justiça, ao cancelar o enunciado de sua súmula nº 512.

O privilégio tem o condão de diminuir a pena de um a dois terços e demanda a presença de alguns requisitos cumulativos, quais sejam, a i) primariedade e ii) e bons antecedentes do agente, a iii) não dedicação a atividades criminosas e, por fim, iv) não integração de organização criminosa. Na ausência de um destes elementos inviabiliza-se o reconhecimento da causa de diminuição.

No tocante ao requisito da dedicação a atividades criminosas, tem-se que alguns fatores podem denotar habitualidade e envolvimento no crime, impedindo o reconhecimento da figura privilegiada.

Exemplo disso é a constatação de inquéritos policiais e ações penais em andamento que, a despeito de ser inválida para exasperação da pena base, pode influenciar na convicção do Juiz para impedir a redução do § 4º, do art. 33 da Lei de Drogas.

De igual modo, nada impede considerar o registro de atos infracionais do agente, enquanto adolescente, a reforçar o convencimento do Magistrado acerca do envolvimento em atividades criminosas.

Ora, é cediço que o registro de ato infracional, mormente quando plurais e análogos ao tráfico de drogas, denotam que o agente se dedica com habitualidade ao crime, fazendo do meio espúrio verdadeiro meio de vida.

Não se descarta que a fase adolescente é considerada irresponsável perante a sociedade e ao direito, todavia, ainda que os reflexos dos comportamentos desviados sejam anulados com a maioridade, considerar os atos infracionais como fatores indicativos de dedicação ao crime não encontra obstáculo no sistema jurídico. A própria expressão disposta no § 4º, do art. 33 da Lei de Drogas, “não se dedique a atividades criminosas”, não exclui do seu conceito os atos infracionais, nitidamente hábeis a indicar propensão ao crime.

A rigor, essa a intenção da figura do tráfico privilegiado: alcançar e beneficiar, com a redução de pena, os indivíduos que ocasionalmente se envolveram em situação ilícita, e não premiar o indivíduo que, de longa data, faz do crime o seu meio de vida.

Não destoa desse entendimento o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N.11.343/2006. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADE CRIMINOSA. REGISTRO DE ATO INFRACIONAL. INAPLICABILIDADE. ALTERAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO. REEXAME DE PROVAS. REGIME MAIS GRAVOSO (FECHADO). PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MODO ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. INVIABILIDADE. FALTA DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, os condenados pelo crime de

tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa.

3. O registro de atos infracionais é elemento idôneo para afastar a figura do tráfico privilegiado, quando evidencia a propensão do agente a práticas criminosas. Precedentes da Quinta Turma.

4. Concluído pelas instâncias antecedentes que o paciente se dedica ao comércio ilícito de entorpecentes, tendo em vista, além da quantidade e da variedade da droga apreendida (60,50g de maconha e 7,67g de cocaína), o fato de que ao tempo do delito em apreço, ele estava no curso de liberdade assistida pela prática de ato infracional análogo ao tráfico de drogas, a modificação desse entendimento, a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas, enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. Precedentes.

5. Estabelecida a pena definitiva em 5 anos de reclusão, revela-se correta a imposição inicial do regime fechado (mais grave segundo o quantum da sanção aplicada), tendo em vista a análise desfavorável das circunstâncias judiciais, conforme o art. 33, § 2º, "a", e § 3º, c.c. o art. 59, ambos do CP, e o art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Precedentes.

6. É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante do quantum da sanção aplicada (art. 44, I, do Código Penal).

7. Habeas corpus não conhecido.

(HC 364.837/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 01/02/2017).

Também já decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo:

Apelação - Tráfico de drogas - Recurso Ministerial e Defensivo - Ausência de impugnação no tocante ao mérito - Réu confesso em juízo - Confissão corroborada pelos demais elementos de prova - Acusado preso em flagrante delito na posse de 54 gramas de cocaína e 84 gramas de maconha embaladas para o comércio ilícito - Condenação de rigor.

Dosimetria - Redução da pena-base ao mínimo legal - Dolo normal à espécie delitiva - Impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo pelo reconhecimento das atenuantes da menoridade e confissão - Afastamento da causa de diminuição do §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06 - A prática de atos infracionais em delitos da mesma natureza demonstram a dedicação à atividade criminosa e impedem a concessão da benesse - Inaplicabilidade da substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos - Benesse que não se mostra suficiente para reprovação e prevenção do crime - Mantido o regime fechado.

Recurso parcialmente provido para a defesa e provido para o Ministério Público.

(Apelação nº 0003322-24.2013.8.26.0050. Voto nº 29.979. 11ª Câmara de Direito Criminal. Des. Rel. Salles Abreu. Julgado em 02.04.2014).

De mais a mais, admite-se a utilização de atos infracionais para fundamentar a prisão preventiva do agente, pois podem ser sopesadas para indicar que o agente se dedica a atividades criminosas.

Nessa linha de ideias, não haveria coerência em se admitir a consideração de registros de atos infracionais para fundamentar a segregação cautelar e não se admitir para desaconselhar o reconhecimento do privilégio do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Evidentemente que o simples registro de ato infracional não indica, peremptoriamente, dedicação a atividades criminosas a impedir a benesse em voga. Porém, atos infracionais i) análogos ao tráfico de drogas, ii) reiterados e iii) anotados em curto espaço de tempo com o crime em apuração apontam seguramente para o envolvimento habitual do agente com atividades criminosas.

Assim, não há ilegalidade na sentença que deixa de aplicar a redução do § 4º, art. 33, da Lei 11.343/06, quando se verifica, sopesando os registros de atos infracionais, que o agente se dedica a atividades criminosas.

Entendo não ser possível, também, pelo mesmo motivo, a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

Em que pese o Colendo Supremo Tribunal Federal ter reconhecido a inconstitucionalidade do art. 44 da Lei nº 11.343/06 por ocasião do julgamento do

HC nº 97.256/RS, e a resolução do Senado Federal suspendendo a execução de parte do dispositivo legal, a vedação de se aplicar penas restritivas ao crime de tráfico continua sendo possível quando as circunstâncias do art. 44, III, do Código Penal indicarem não ser recomendável a substituição, como ocorre no caso em apreço. É que o STF afastou a proibição que a lei trazia, mas não tornou obrigatória a substituição. Esta somente será possível quando as circunstâncias do fato apontarem como suficiente e recomendável a substituição. E, definitivamente, não se demonstra razoável conceder tamanho beneplácito aos que praticam tão grave crime como o tratado nestes autos.

Ao contrário, estes merecem severa reprimenda, pois se trata de crime em que a base da sociedade é atingida, distorcendo regras e valores dos jovens, de forma a aumentar a já tão elevada criminalidade. O traficante age sem qualquer escrúpulo, com exclusiva intenção de lucro, não se importando em destruir diversos lares e famílias quando leva ou mantém no vício um de seus integrantes.

O legislador, ao equiparar o crime de tráfico ilícito de entorpecentes aos crimes hediondos, em norma constitucional (art. 5º, XLIII, da CF), deixou claro seu intuito em dar tratamento rigoroso aos que praticam este crime, determinando, ainda, que o regime inicial de cumprimento de pena será, obrigatoriamente, o fechado (art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90).

O E. Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, embora sem impedimento legal, é incompatível com a condenação por crime hediondo, mesmo que equiparado, em razão da periculosidade social presumida, que incompatibiliza o autor do crime com atividades comunitárias ou assistenciais na medida em que o coloca em contato direto com grupo social passível de seu assédio. Ademais, em face do contexto em que o crime foi praticado, que exterioriza a personalidade do agente e seu desprezo pela vida em sociedade, eis que o envolvimento com o tráfico fomenta a multiplicação de outros crimes, não se mostra suficiente a referida benesse. Isso porque, com base no art. 44, III, do CP, tem-se que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos somente se mostra adequada quando suficiente ao atendimento das finalidades retributiva, preventiva e reprovadora da conduta, o que não se mostra no presente caso (TJ/SP, Apelação 0006123-68.2013.8.26.0451, Comarca de Piracicaba, 13ª Câmara de Direito Criminal, v.u., Des. Rel. Augusto de Siqueira, j. em 08 de maio de 2014, publicada no dia 27 de maio de 2014).

Deve ser decretado o perdimento do dinheiro apreendido em poder do réu, com base no art. 63, Lei n. 11.343/06.

Do pedido final:

Ante o exposto, requeiro seja julgada procedente a presente ação penal.

Dada a palavra ao(à) nobre defensor(a) do(a)(s) acusado(a)(s) João Vitor, manifestando-se sua Excelência, conforme gravação diretamente no Teams.

Dada a palavra ao(à) nobre defensor(a) do(a)(s) acusado(a)(s) Jean, manifestando-se sua Excelência, conforme gravação diretamente no Teams.

Em seguida pelo(a) MM.Juiz(a) foi dito o seguinte:

Passo a proferir a seguinte sentença:

VISTOS.

JOÃO VITOR SANTOS DE OLIVEIRA e JEAN SEBASTIÃO RIBEIRO BARBOSA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, em concurso de pessoas (CP, art. 29), porque no dia 27 de setembro de 2021, por volta de 13h, na Rua das Oliveiras, Bairro Mário Dedini, nesta cidade e Comarca de Piracicaba/SP, atuando em conluio e com unidade de desígnios delituosos, traziam consigo e transportavam, para entregar ou fornecer ao consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, 31 (trinta e um) invólucros plásticos contendo Cannabis Sativa L., "maconha", com peso líquido de 33,3g (trinta e três gramas e três decigramas), e 28 (vinte e oito) invólucros em plástico e papel alumínio contendo cocaína, com peso líquido de 6,5g (seis gramas e cinco decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, JOÃO e JEAN - que desde a adolescência se dedicam ao tráfico de

drogas - se ajustaram para a prática de tráfico de drogas utilizando-se da motocicleta Honda CG/Titan, ESD-8939, Sumaré/SP.

Ocorre que, quando transportavam entorpecentes, foram interpelados por policiais militares que suspeitaram do comportamento do condutor - a motocicleta estava sem emplacamento, em alta velocidade e realizando manobras perigosas.

Não obedecendo aos sinais de parada, JEAN, trazendo JOÃO como passageiro, iniciou fuga pelas ruas da cidade. A abordagem policial somente foi possível após os réus sofrerem queda da moto no bairro Bosque dos Lenheiros.

Em busca pessoal, com JOÃO foram encontradas as drogas acima descritas e R\$5,00 (cinco reais) em espécie (fls. 24/27); com JEAN - que ainda seguiu em fuga e foi abordado adiante - nada de ilícito foi encontrado.

Informalmente, os réus confirmaram a aquisição da droga no bairro Santa Teresinha para venda no Bosque dos Lenheiros (fls. 04/07).

Na Delegacia, porém, ambos negaram relação com a droga apreendida (fls. 08/11).

O exame pericial constatou a presença de Tetrahidrocannabinol e cocaína nas substâncias apreendidas (auto fls. 19/20 e laudo fls. 29/31).

As circunstâncias da prisão, notadamente a condição pessoal dos réus- cumprimento recente de medidas socioeducativas pela prática de atos infracionais análogos ao tráfico de drogas - a fuga dos policiais, bem como a apreensão de considerável quantidade de cocaína e maconha - incompatíveis com a alegação de mero uso pessoal -, tornam certo que os réus, concluídos, transportavam e traziam consigo os entorpecentes com a finalidade de comércio ilícito.

A denúncia foi oferecida, sem oferecimento de acordo de não persecução penal (fls. 149), sendo determinada a notificação dos réus para oferecer defesa prévia, nos termos do artigo 55 da Lei nº 11.343/06 (fls. 153).

Os réus foram notificados (fls. 188 e 190) e apresentaram defesas prévias. Jean alegou inocência (fls. 194/196) e João Vitor alegou a ilegalidade da não ocorrência de audiência de custódia e negou a prática delitiva, aduzindo sua inocência (fls. 158/160).

A denúncia foi recebida, designando-se a audiência virtual (fls. 208/211). Os réus foram citados (fls. 251 e 253).

Durante a instrução, foram ouvidas 02 testemunhas comuns e uma testemunha de defesa do réu Jean, sendo os réus interrogados.

Encerrada a instrução, em memoriais e debates orais, as partes se manifestam.

É o relatório.

DECIDO.

I - Da preliminar

1) A Defesa de João requereu a conversão do julgamento em diligência, para oitiva da atendente da sorveteria, mencionada por Jean.

Não é caso de deferimento do pedido. Inicialmente, os réus estão sendo defendidos por advogados constituídos e, por isso, a Defesa tinha condições de saber, antes da presente audiência, se havia alguma testemunha essencial ao deslinde da ação.

De mais a mais, consoante se verifica dos autos, a suposta testemunha apenas seria capaz de indicar se os réus estavam ou não tomando sorvete, sem qualquer outra informação, de maneira que, apenas isso, não seria suficiente para afastar a acusação.

E isso é certo, porque os réus poderiam ter adquirido a droga antes de pararem na sorveteria e ninguém nesse comércio seria capaz de confirmar qualquer versão.

Assim, indefiro o pedido da Defesa.

2) Quanto à audiência de custódia, ao contrário da manifestação defensiva, é certo que a dispensa da realização dessas audiências encontrava respaldo na Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, que teve sua vigência prorrogada pela recomendação de nº 91/21, acompanhada pelo Provimento nº 2548/2020 do Conselho Superior da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

De outra banda, somente a partir do dia 04 de outubro de 2021 foi retomada a realização das audiências em comento, nos termos do Provimento Conjunto nº 46/2021, editado pela Presidência deste Tribunal em conjunto com a Corregedoria Geral de Justiça.

No caso dos autos, verifica-se que a prisão dos réus ocorreu em 27 de setembro de

2021, sendo convertida em prisão preventiva no dia seguinte pela decisão de fls. 76/79; logo, antes da retomada do ato.

Além do mais, a ausência de realização do ato não implica diretamente em revogação da custódia cautelar. Conforme entendimento das cortes superiores, assegurado o direito de manifestação das partes, sua conversão é válida.

Neste sentido:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO EXARADA NA ADPF 347- MC/DF. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO, PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, DA DECISÃO EXARADA POR ESTA RELATORA NESTES AUTOS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PLEITO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA NÃO REALIZAÇÃO, DENTRO DO PRAZO DE 24h, DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. A OBRIGATORIDADE DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO CONDUZ A CONCLUSÃO DE QUE A SUA INOBSERVÂNCIA IMPLICA EM SOLTURA IMEDIATA DO FLAGRANTEADO. 1. A audiência de custódia constitui, nos termos de iterativa jurisprudência desta Corte, direito subjetivo do preso, motivo pelo qual, mesmo no atual cenário de Pandemia da Covid-19, deve ser realizada, presencialmente ou por videoconferência, pelo Juízo competente. 2. Ante a inexistência de documentos comprobatórios, inviável a constatação de eventual descumprimento da decisão monocrática por mim proferida. 3. Ausência de demonstração de prejuízo obstaculiza o reconhecimento de nulidade do ato. Precedentes. 4. O relaxamento da prisão em decorrência da não realização da audiência de custódia consiste tema estranho ao paradigma de controle invocado (ADPF 347-MC/DF). Desse modo, à míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade da decisão desta Suprema Corte. 5. Considerando a decisão monocrática do Ministro Luiz Fux, Presidente deste Supremo Tribunal Federal, na ADI 6.299- MC/DF, suspendendo a eficácia do artigo 310, §4º, do Código de Processo Penal (CPP), na redação introduzida pela Lei nº 13.964/2019, e tendo em vista a atual jurisprudência desta Corte, a obrigatoriedade de realização da audiência de custódia dentro do prazo de 24h (vinte quatro horas) após a prisão em flagrante não conduz a conclusão de que a sua inobservância implica no imediato relaxamento da privação cautelar de liberdade, notadamente nos casos em que decretada a prisão preventiva. 6. Agravo regimental conhecido e não provido. (Rcl 44456 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 08/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-069 DIVULG 12-04-2021 PUBLIC 13-04-2021)

E ainda:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ALTERAÇÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA. INVIÁVEL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Quanto à não realização da audiência de custódia, destaco que "o entendimento majoritário desta Sexta Turma é no sentido de que a não realização da audiência de custódia não enseja nulidade da prisão preventiva em que posteriormente convertida, pois, observadas as outras garantias processuais e constitucionais, resta superado o exame desse tema. A propósito: gRg no HC 353.887/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 07/06/2016; RHC 76.906/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 24/11/2016; RHC 63632/PR, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 18/11/2016. Cabe ressaltar ainda que a excepcionalidade do período de pandemia da doença Covid-19, pelo qual estamos passando, validamente permite a decretação da custódia cautelar sem a audiência de custódia" (AgRg no HC n. 630.066/MG, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 2/3/2021, DJe 5/3/2021). 2. Dessa forma, ausente a ilegalidade arguida pela não realização da audiência de custódia, especialmente em razão de ter sido oportunizada manifestação prévia da defesa antes da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. 3. Com relação à alegação de que a conduta se amoldaria à contravenção penal de vias de fato, destaco que não é viável em habeas corpus a análise de matéria fático-probatória com o fim de

alterar a capitulação dada pelas instâncias de origem. 4. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 5. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais 7. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 8. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 9. Ordem denegada. (HC 677.072/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 22/10/2021).

II - Do mérito

A ação penal é procedente.

1) Da materialidade

A materialidade criminosa está consubstanciada no auto de exibição e apreensão de fls. 19/20, nas fotografias de fls. 25/27, no laudo de constatação de fls. 30/31, bem como no exame químico-toxicológico de fls. 174/176, segundo o qual foi detectado a presença de Tetrahydrocannabinol (THC) e cocaína nas substâncias apreendidas.

2) Da autoria

A autoria ficou demonstrada nos autos.

Na fase investigativa, o réu João Vitor alegou que a drogas não são de sua propriedade e que não estavam com droga. Falou para Jean parar a moto, contudo, Jean não o ouviu. Trabalha de pedreiro (fls. 08).

Em Juízo, o réu João Vitor disse que ele e Jean foram tomar sorvete e estavam indo embora. Atravessaram a encruzilhada da avenida e Jean não obedeceu, porque não tinha habilitação e a moto não era dele. Na fuga, Jean não estava em alta velocidade, não desobedeceu semáforos e placas de parada obrigatória. Por isso, foram até o Bosque dos Lenheiros. Pulou da moto na mata e ficou parado, sendo abordado pelo policial. Jean continuou a ação e foi abordado. Foram levados à casa da mulher de Jean. Os policiais disseram que seriam levados à Delegacia por direção perigosa, no entanto, chegando lá, apresentaram uma bolsinha de drogas. A bolsinha não lhes pertencia. Enquanto estava abordado, os policiais não encontraram nada na área de mata. Não abordaram antes, porque Jean não queria perder a moto. Não usa drogas.

Na Delegacia de Polícia, o réu Jean também alegou que a drogas não são de sua propriedade. Não estava com droga. A moto era emprestada de um amigo e, por ter duas filhas pequenas, pegou a moto para ir comprar sorvete. A moto é de um vizinho de nome de Luís. Trabalha de servente de pedreiro (fls. 10).

Em solo judicial, o réu Jean contou que estava na sorveteria com João. Foram atendidos por uma atendente e foram embora. O policial deu ordem de parada e ficou com medo de perdê-la. Acabou correndo e passou pela mata. Caiu e tentou correr novamente, parando em frente da sua casa. O policial disse que iria para a Delegacia, assinar direção perigosa, mas na Delegacia, os policiais apresentaram a droga. Não teria ido à sorveteria com drogas. Não sabe explicar quanto tempo demorou para parar, cerca de 5 minutos. Quando fugiu, acelerou bastante, mas não passou em cruzamento nem em farol fechado. Não passou por dentro de comunidade. Na frente das casas, havia pessoas, mas não na rua. A droga não era deles. Os policiais ficaram bravos, por ter corrido. Usa maconha, mas consegue ficar sem consumi-la.

As alegações dos réus foram afastadas pelos demais elementos de prova. Vejamos. O policial militar Anderson Cleiton Floriano relatou que estavam em patrulhamento, quando avistaram uma motocicleta cruzando a avenida onde estavam. Nesse momento, o condutor da motocicleta fez uma manobra levantando a roda da frente e, por isso, fizeram o acompanhamento. Verificaram que a moto estava sem emplacamento. Começaram

a dar sinais sonoros e luminosos, mas a moto continuava. O acompanhamento seguiu por vários bairros. O condutor da motocicleta não obedeceu às ordens de parada. Quando acessou o bairro Gilda, numa área verde, o condutor perdeu o controle da moto e o passageiro caiu da garupa. O policial Sd. Gonçalves realizou a abordagem do passageiro e continuou no encalço do condutor da moto. Chegou ajuda de outras viaturas e do Águia e conseguiu abordar o condutor. Voltaram até o local onde o passageiro tinha sido abordado. João, o passageiro, estava com uma pochete na cintura, tentou se desfazer dela, mas foi impedido pelo Sd. Gonçalves. Dentro da pochete, havia maconha e cocaína, além de R\$ 50,00. Indagados sobre a droga, eles informaram que teriam ido buscar a droga no bairro Santa Terezinha e a venderiam no Bosque dos Lenheiros. Eles não disseram de quem haviam adquirido a droga. Deram voz de prisão aos réus. A moto não constava queixa de roubo ou furto. Durante o acompanhamento, o motociclista não obedeceu aos sinais de parada obrigatória, conduziu a moto nas comunidades Frederico e o Bosque dos Lenheiros com várias crianças brincando na rua, em velocidade bem acima daquilo que a via permite. Jean conduzia a moto. Não conhecia os réus. O acompanhamento demorou em torno de pelo menos 15 minutos, até conseguirem abordar Jean. Ele passou por vários bairros. O também policial militar Robison Alas Gonçalves esclareceu que estavam em patrulhamento, quando se depararam com dois indivíduos em uma moto, fazendo manobra, empinando a moto na via pública. Foram abordá-los, mas eles se evadiram. O acompanhamento demorou bastante tempo, passando por vários bairros, por cerca de 15 minutos. Durante o acompanhamento, o piloto não respeitou sinais de parada obrigatória, semáforo, em alta velocidade, quase atropelando os pedestres e, inclusive, quando faziam o acompanhamento, o baú da sua motocicleta chegou a abrir e seus pertences ficaram pelo chão, sendo recuperados por outros policiais. Depois de um bom tempo, eles tentaram entrar no bairro Gilda, num lugar de mata e o garupa caiu da moto. Seu parceiro foi atrás do piloto e parou, para abordar o garupa. Nesse momento, ele tentou dispensar a pochete, mas conseguiu impedi-lo. Conteve o indivíduo e efetuou o algemamento. Quando seu parceiro voltou, foram verificar a pochete e, dentro dela, havia drogas e acabaram prendendo ambos. Abordou o réu de pele mais clara, identificado como João. O condutor da moto foi abordado por seu parceiro. Depois, os réus informaram que tinham pegado a droga no bairro Santa Terezinha, para fazer a revenda. Indagaram de quem eles teriam comprado, mas eles não informaram. Não conhecia os réus. Havia pedestres na rua, muitas pessoas. Quem devolveu seus objetos que caíram foram pedestres. Na área de mata, não havia pessoas. Jean foi abordado quase na frente da casa dele. Dentro da pochete, havia dinheiro, R\$ 5,00. Havia cerca de 40 porções de drogas.

Marlene da Costa Pereira, proprietária da sorveteria, contou que não conhece os réus e não sabe o motivo da sua intimação. Não fica quase na loja e não viu o acompanhamento. É raro ficar na loja.

A primeira questão a ser analisada nos autos é o envolvimento do réu com a droga apreendida.

Ambos os réus, em solo policial e em audiência, negaram a propriedade ou a posse do entorpecente apreendido.

Os policiais militares relataram que estavam em patrulhamento, avistaram a motocicleta conduzida por Jean e com João na garupa, sem emplacamento, e realizando manobras com somente umas das rodas. Diante deste fato, iniciaram um acompanhamento, com sinais sonoros e luminosos acionados. O acompanhamento durou mais de 15 minutos, porque o condutor não obedeceu às ordens de parada. No bairro Bosque dos Lenheiros, Jean acessou uma área de mata e perdeu o controle da motocicleta, o que fez com que o garupa caísse e fosse abordado pelo policial Gonçalves. O condutor ainda continuou empreendendo fuga pilotando a motocicleta, mas foi alcançado pelo policial, que conseguiu abordá-lo. Em revista pessoal, com Jean, nada foi encontrado, no entanto, com João havia uma pochete, na qual os policiais apreenderam 31 porções de maconha, 28 porções de cocaína e R\$ 5,00 em dinheiro. Informalmente, aos policiais militares, os réus confessaram que tinham adquirido a droga no bairro Santa Terezinha e que a iria revender no bairro Bosque dos Lenheiros.

A testemunha de defesa nada soube dizer sobre os fatos, que não presenciou.

A primeira questão a ser resolvida é sobre a posse da droga.

Nesse tema, temos duas versões: a dos réus, que negam qualquer envolvimento com a droga, e a dos policiais militares, que revelaram que a droga estava com o garupa João.

Resta saber qual versão merece credibilidade.

Num primeiro momento, percebe-se que Jean não obedeceu à ordem de parada obrigatória, imprimindo maior velocidade à motocicleta e a conduzindo de forma irregular.

Na medida em que se iniciou o acompanhamento da motocicleta, o helicóptero da Polícia Militar precisou auxiliar as viaturas terrestres, em razão a rapidez do deslocamento do veículo acompanhado.

De mais a mais, pouco provável que o proprietário da motocicleta a utilizasse sem emplacamento, se não estivesse em conduta ilícita.

Essas situações indicam que os réus tinham ciência da ilicitude, na medida em que a motocicleta, embora estivesse sem emplacamento, não era produto de crime e estava com a documentação regularizada.

Assim, temos que dar credibilidade à versão uníssona e segura dos policiais militares.

Ainda que assim não fosse, os policiais militares, como funcionários públicos, não estão impedidos de depor. Por outro lado, a palavra dos agentes policiais tem validade como prova, a menos que haja alguma prova de que têm interesse no resultado da demanda penal, que inexistente no caso concreto.

Nesse sentido, já se manifestou o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

(...) 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...) (AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019). (...) IV - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (...) (HC 471.082/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 30/10/2018).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido. (HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018 - grifei).

Assim, a distinção cabível, neste momento processual, é sobre a existência do dolo

que comprove a traficância.

O elemento subjetivo do tipo, como diz respeito à intenção do agente, contida em seu interior, não é perceptível logo de início, mas sim aferível por meio das circunstâncias externas que acabam por traduzir o interior do agente. Entende a jurisprudência:

"O aferidor, que marca as fronteiras entre os tipos penais previstos nos artigos 12 e 16 da Lei 6368/76, reside na finalidade com que a erva é guardada, transportada, adquirida ou tida em depósito. Se para exclusivo uso próprio o delito é o do artigo 16 e, caso contrário, se configura do artigo 12" (TJRS - Ver. 695102699 - Rel. José Eugênio Tedesco - RJTJRS 175/54).

"Para a caracterização do crime de narcotráfico, como em relação aos demais delitos punidos na Lei 6368/76, atender-se-á à quantidade da substância apreendida, ao local e condições em que se desenvolveram a ação criminosa, às circunstâncias da prisão, bem como à conduta e aos antecedentes do agente, tal como dispõe o artigo 37, da referida lei" (TJRS - Ver. - Rel. Rubens Rebelo Magalhães - RJTJRS 74/11). No caso dos autos, os réus aduziram que a droga não estava com eles e que não tinham relação com ela, nada mencionando sobre sua destinação. A prova, contudo, confirma a destinação de consumo de terceiras pessoas.

Inicialmente, Jean empreendeu fuga por 15 minutos, tentando de todas as formas impedir a abordagem policial, revelando, com isso, que tinha conhecimento de que transportava entorpecente.

A quantidade e diversidade de droga apreendida (31 porções de maconha, 28 porções de cocaína) também indica que encontrada indica que seriam utilizadas para a mercancia ilícita, uma vez que os usuários não costumam manter tanta quantidade de droga em seu poder, na rua.

Com o réu João, além da droga, havia dinheiro de origem lícita não confirmada.

Por fim, informalmente, aos policiais militares, no momento da abordagem, os réus confessaram que a droga era destinada à venda, no bairro Bosque dos Lenheiros.

Assim, a fuga perpetrada pelos réus, a quantidade e diversidade da droga apreendida, a existência de dinheiro em poder de João, a confissão informal; tudo revela que a droga apreendida tinha como destinação o consumo de terceiras pessoas. Ressalto que ainda que o réu Jean seja usuário de entorpecente, a traficância não fica afastada, uma vez que várias pessoas nessas condições acabam por vender entorpecentes até mesmo para sustentar o vício ou pagar dívida de drogas. Além disso, a dependência refere-se à imputabilidade e não à caracterização do delito.

Diz a jurisprudência:

"A condição de dependente químico não elide a prática do delito de tráfico de drogas." (TJAC - Processo: EI 10414920108010001 AC 0001041-49.2010.8.01.0001 - Relator(a): Pedro Ranzi - Julgamento: 27/04/2011 - Órgão Julgador: Tribunal Pleno - Publicação: 30/04/2011).

"APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVA. SUFICIÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE DE ENTORPECENTE. DESCABIMENTO. Acusada que admitiu a venda de entorpecentes. Apreensão de grande quantidade de "crack", aliada às demais circunstâncias do flagrante, que impedem a conclusão de que os entorpecentes se destinassem ao consumo próprio. FIGURA DO USUÁRIO-TRAFICANTE. A condição de dependente químico está relacionada ao conceito de imputabilidade (pressuposto de aplicação da pena) e não interfere na subsunção do fato ao tipo penal. Condição de toxicômano que não elide a conclusão de que a ré se dedicava à narcotraficância. Figura do usuário-traficante amplamente admitida pelos tribunais. Defesa, ademais, que sequer se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada dependência química da acusada. Condenação pelo crime de tráfico mantida. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO." (TJSP - Processo: APL 182718720088260451 SP 0018271-87.2008.8.26.0451 - Relator(a): Amado de Faria - Julgamento: 13/09/2012 - Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal - Publicação: 20/09/2012).

"A simples alegação de o agente ser viciado em drogas não tem o condão de desclassificar a conduta, mormente se surpreendido na posse de grande quantidade de entorpecente, de molde a evidenciar finalidade de venda" (TJRN, Ap. 00.001954-2, Câ. Crim., j. 1º.06.2001, rel. Juiz João Rebouças, V.U., RT 796/688).

"A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente

na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando à última, de maior gravidade" (TJSP - HC 42.229-3 - Rel. Onei Raphael - RJTJSP 101/498).

"Tráfico de entorpecente - Grande quantidade da droga apreendida em poder do acusado, evidenciadora do propósito de comercialização - Desclassificação para uso, em razão da dependência, inadmissível - Inteligência dos artigos 12 e 16 da Lei n.º 6.368/76" (TJMT - AC 565/86 - Rel. Mauro José Pereira - RT 620/331).

A condenação, assim, é de rigor.

3) Do dispositivo e da pena

Na dosagem da pena, devem ser levadas em consideração as diretrizes do artigo 59 do Código Penal.

O réu João não possui maus antecedentes criminais, de forma que sua pena-base deve ser calculada no mínimo legal: reclusão de 05 anos e 500 dias-multa.

A menoridade não é capaz de trazer a pena aquém do mínimo legal.

Embora o João seja primário, a causa de diminuição da pena do parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, não pode ser aplicada. É que ele já foi processado pela prática de ato infracional equiparado ao tráfico de drogas (Processo nº 1501023-77.2021.8.26.0451 que tramitou perante a Vara da Infância e Juventude local), no qual lhe foi concedida a remissão, com aplicação de medida socioeducativa de liberdade assistida, que nem chegou a ser cumprida. Demonstrou, pois, a reiteração da atividade ilícita, que lhe servia de sustento, de forma que a